

1501607-72.2022.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... meios policiais pela prática do tráfico ilícito. Finalmente, ressaltou a surpresa de Eliana quando as drogas foram encontradas.

Pois bem. Como se vê, as provas são suficientes apenas para a segura comprovação do crime de tráfico atribuído aos réus Richard e Douglas.

Cumpre, desde logo, observar que inexistente vedação legal ou constitucional à notícia anônima de crime. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501607-72.2022.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2096091/2022 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 24157265 - CENTRAL

POL.JUD-JAÚ, 2096091 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIELA APARECIDA DA SILVA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

GABRIELA APARECIDA DA SILVA, RICHARD GABRIEL DOS SANTOS DE PAULA, DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS DE PAULA e ELIANA LÚCIA DOS SANTOS estão sendo processados como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, combinados com o artigo 40, inciso VI (envolvimento de adolescente) também da Lei nº 11.343/06, em concurso material.

Notificados (fls. 224, 226, 227 e 228), os réus apresentaram resposta à acusação às fls. 229/235.

A denúncia foi recebida em 8 de junho de 2022 (fls. 236/237).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas de acusação e os acusados foram interrogados (fls. 272).

Em debates orais, o representante do Ministério Público requereu a condenação dos réus Douglas e Richard pelo crime de tráfico e a absolvição pelo delito de associação e também a absolvição das rés Eliana e Gabriela (fls. 272).

A defesa postulou a desclassificação do delito imputado aos réus Richard e Douglas para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, teceu ponderações acerca de eventual aplicação da pena e requereu a absolvição das rés Eliana e Gabriela (fls. 272).

É o relatório.
Fundamento e DECIDO.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva do tráfico praticado por Douglas e Richard restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 7/11), boletim de ocorrência (fls. 24/28), auto de exibição e apreensão (fls. 29/30), fotografias (fls. 44/47 e 57/61), informação (fls. 68/70) e laudos periciais (fls. 143/149 e 150/158), além da prova oral.

Em juízo, Richard rechaçou a acusação e disse que a droga encontrada na casa de sua mãe pertencia ao seu irmão Douglas. Disse que a maconha encontrada em sua casa se destinava ao seu consumo e lhe tinha sido dada por Douglas no dia anterior aos fatos. Usava o celular apreendido, assim como seu irmão e Gabriela. Nada sabe sobre as mensagens encontradas. É usuário de drogas desde os 14 anos.

A ré Gabriela negou a prática de tráfico e disse que a droga que estava em sua casa seria destinada ao uso de seu marido e havia sido dada a ele por Douglas. O celular apreendido lhe pertencia, mas permanecia com Richard e com Douglas a maior parte do tempo. No dia anterior aos fatos, Douglas esteve em sua casa e foi embora por volta das 19h00m, levou o celular com ele e acredita que tenha devolvido o aparelho em torno de 2h00m. Não sabia do diálogo encontrado no aparelho. Sabe que a droga que estava na casa de Eliana pertencia a Douglas. O prato que foi apreendido em sua casa estava sujo de comida.

O réu Douglas rechaçou a acusação e afirmou que, alguns dias antes da prisão de Richard, havia trocado uma motocicleta por maconha já fracionada na cidade de Bauru e, no dia anterior aos fatos, por volta de 11h00m, foi à casa de Richard e lhe deu dez porções, pois consumiam drogas todos os dias. Guardou o restante da maconha na casa de sua mãe (Eliana). Comprou a balança para conferir o peso da maconha adquirida, a qual pesava na embalagem. Costumava usar o celular de Gabriela, mas negou tê-lo levado para sua casa ou ter enviado as mensagens encontradas pelos policiais. No dia anterior aos fatos, saiu da casa de Richard em torno de 21h00m. Estava trabalhando com seu tio como pedreiro e recebia cerca de R\$80,00 ao dia. Conhece o adolescente Kauê desde criança. Chegou a pé na casa de seu irmão no momento da diligência de busca e não estava com Kauê. Fugiu ao perceber a presença dos policiais, por conta das drogas que possuía. Negou, finalmente, que tivesse ido à casa de sua mãe quando os policiais estavam lá.

A ré Eliana negou os crimes que lhe são imputados. Argumentou que, na data dos fatos, soube que a polícia havia invadido a casa de seu filho, então foi até lá e, posteriormente, ao escritório do advogado. Quando retornou à sua residência, os policiais já estavam na porta e perguntaram se havia drogas ali, o que negou. Autorizou a entrada deles, que encontraram droga no quarto de Douglas. Os policiais

apreenderam seu celular e um valor oriundo da pensão de INSS que havia recebido. Sabe que os seus filhos são usuários, todavia não tem conhecimento de que comercializassem entorpecentes. Além de ser pensionista, trabalha com faxineira.

O policial civil Bruno contou ter recebido denúncias de que Richard comercializava drogas, o que ensejou a expedição de mandado de busca e apreensão na residência dele. Durante a diligência, localizou, na cozinha, em um prato em cima da mesa, algumas porções de maconha. A mãe dele (a ré Eliana) chegou ao local e foi solicitada por Richard que avisasse ao advogado, bem como a outros dois indivíduos, acerca da prisão. Eliana franqueou a entrada dos policiais em sua residência e negou que houvesse drogas ali. No imóvel, apreenderam (dentro de um baú) várias porções de maconha (idênticas às encontradas na casa de Richard), além de uma porção maior, uma balança de precisão e dinheiro. Enquanto lá estavam, chegaram dois indivíduos em um veículo VW Gol, que, ao perecerem a presença da polícia, empreenderam fuga.

O policial civil Paulo confirmou a narrativa de seu colega e acrescentou que no celular de Gabriela havia diálogos indicativos da participação dela no comércio espúrio. Informou que os dois indivíduos mencionados pelo policial Bruno seriam o réu Douglas e o menor Kauê, que é conhecido nos meios policiais pela prática do tráfico ilícito. Finalmente, ressaltou a surpresa de Eliana quando as drogas foram encontradas.

Pois bem. Como se vê, as provas são suficientes apenas para a segura comprovação do crime de tráfico atribuído aos réus Richard e Douglas.

Cumpre, desde logo, observar que inexistente vedação legal ou constitucional à notícia anônima de crime. Como bem se sabe, o Poder Público incentiva a população a que informe às autoridades os fatos criminosos de que tenham conhecimento, visando, assim, dar mais efetividade à prevenção e à repressão de delitos.

Nessas situações, a pessoa não é compelida a se identificar, o que incentiva a participação da comunidade no combate à criminalidade. Portanto, seria um contrassenso estimular a sociedade a denunciar uma atividade delituosa para, depois, infirmar esse elemento de convicção e considerar contaminadas todas as provas subseqüentes, ainda que produzidas lícitamente a partir daquela.

Destarte, as informações recebidas e investigadas pelos policiais foram confirmadas com o cumprimento do mandado de busca e apreensão e o encontro de drogas, além de apetrechos comumente utilizados para embalagens de entorpecentes, e também pelos diálogos encontrados em um dos celulares apreendidos (fls. 29/30).

Consoante ensina Guilherme de Souza Nucci, “para a correta tipificação da conduta, é fundamental que se verifiquem os elementos pertinentes à natureza da droga, sua quantidade, avaliação do local, condições gerais, circunstâncias que envolvem a ação e a prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (Leis penais e processuais penais comentadas. 2ª ed. São Paulo: RT, p. 307).

As mensagens extraídas do celular que estava na residência de Richard e Gabriela (fls. 68/70), a quantidade de maconha, embalagens e apetrechos (com sujidades de drogas de diferentes espécies – fls. 143/149) apreendidos na casa de Richard e no quarto de Douglas indicam a prática de comércio de entorpecentes por ambos, que, no mais, assumiram a propriedade das drogas.

Não colhe a pálida justificativa apresentada por Douglas sobre a propriedade da balança apreendida, mesmo porque alegou haver pesado a droga na embalagem, mas o referido instrumento apresentava sujidades desta substância (fls. 143/149). Ademais, é inverossímil que o réu, após a compra dos entorpecentes em outra cidade e guarda em sua residência, fosse 'devolver a droga' ou fazer reclamações em caso

de divergência de peso, sobretudo em virtude dos meios intimidatórios normalmente utilizados por traficantes.

E o fato de os réus não terem sido surpreendidos no exato momento da comercialização do entorpecente não afasta a incidência do artigo 33 da Lei 11.343/06, que elenca diversas condutas que se enquadram na prática delituosa prevista no tipo penal.

Nesta senda, decisões proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "TÓXICOS - TRÁFICO - Consumação - Prática de algum ato de tráfico ou "traditio" - Inexigibilidade - Trazer consigo, transportar, ter em depósito ou guardar a substância entorpecente - Suficiência"(...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.007.360-3/6 - São José dos Campos - 6ª Câmara Criminal - Relator Marco Antonio - J. 17.05.2007 - v.u). Voto nº 5.767. "TÓXICOS - Tráfico - Caracterização - Inexistência de dúvida de que a droga apreendida com o acusado e com co-réu se destinava ao consumo de terceiros, levando-se em conta o grande volume e a forma de acondicionamento, embalada separadamente e pronta para a venda, indicando potencial destinação ao mercado nefasto - Desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou mantenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado (...) (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739.

E ainda que os réus sejam usuários de entorpecentes, isso não exclui a possibilidade de que vendam ou armazenem para terceiros, uma vez que tais condutas frequentemente coexistem, até mesmo para sustento do consumo. Sobre o tema, veja-se:

"TOXICO - Tráfico - Absolvição - Inadmissibilidade - Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio - Prova colhida que se direciona nesse sentido - Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância - Condenação mantida - Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 - Ribeirão Preto - 4ª Câmara Criminal - Relator: Bittencourt Rodrigues - 22.08.00 - v.u.)."

Noutra ponta, em relação às acusadas Gabriela e Eliana, observo que as informações recebidas pelos policiais não mencionavam expressamente a participação delas no crime. Ademais, o quarto onde a droga estava acondicionada, malgrado seja localizado na casa de Eliana (que autorizou a entrada dos policiais no imóvel), era usado pelo réu Douglas. Também não restou suficientemente demonstrado, a despeito dos indícios nesse sentido, de que foi Gabriela quem efetivamente travou os diálogos constantes da informação de fls. 68/70.

Assim, e considerando o teor da manifestação ministerial, a ação deve ser julgada improcedente em relação a Eliana e Gabriela e também deve ser afastado o delito de associação indicado na denúncia.

Parcialmente procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Richard Gabriel dos Santos de Paula:

Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, não observo motivos que ensejem a majoração da pena-base, ao que a mantenho no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo - ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-

60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: "Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos"), além da reincidência (fls. 204/205 – Proc. 1500192-10.2020.8.26.0598). Verifico, ainda, a atenuante da menoridade relativa (fls. 56). Assim, majoro a reprimenda para 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na terceira fase, a reincidência do réu enseja o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. No mais, afasto a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006, já que não restou suficientemente comprovada a participação do adolescente Kauê na empreitada criminosa.

Assim, a reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando a reincidência, a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado, nos termos do art. 33, CP.

Por fim, a despeito das alterações promovidas pela Lei 12.736/12 no art. 387, do Código de Processo Penal, especialmente a inclusão da regra trazida no § 2º deste último dispositivo (o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade), deixo de aplicar de forma antecipada a detração penal por entender que esta lei modificadora é materialmente inconstitucional, afrontando os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da isonomia (art. 5º, da Constituição Federal). A propósito, cabe trazer a lume os ensinamentos do Prof. César Dário Mariano da Silva em recente artigo publicado na revista eletrônica Consultor Jurídico:

"O princípio da individualização da pena está previsto no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e dispõe que caberá à lei regular a individualização da pena.

A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.

(...)

A nova lei fundiu em uma etapa a judiciária e a de execução das penas, uma vez que, ao proferir sentença, poderá o Juiz promover de regime o condenado sem atentar para a análise do seu mérito, de acordo com o previsto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: "A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão"

Com efeito, a Lei das Execuções Penais, que é especial, contém normas que devem ser observadas para a correta individualização da pena. O condenado deverá cumprir a pena privativa de liberdade em etapas cada vez menos rigorosas até obter a liberdade, devendo, para tanto, ser observado seu mérito. Sem essa análise do merecimento para a progressão de regime, inclusive com a realização do exame criminológico quando necessário, está sendo violado o disposto no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, que dispõe sobre a individualização da pena.

A Lei a ser observada por ocasião da progressão de regime é a das Execuções Penais, que é especial e traz os requisitos necessários, que devem ser analisados pelo Juiz Natural da causa, que é o das Execuções Penais e não o prolator da sentença.

Destarte, somente com o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 112 da Lei das Execuções Penais é que poderá ser deferida a progressão de regime pelo Juiz das Execuções Criminais, observado o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, CF), a teor do disposto no artigo 66, inciso III, alínea "b", da Lei das Execuções Penais.

E se não bastassem esses argumentos, haverá situações em que pessoas condenadas exatamente às mesmas penas e pelos mesmos crimes terão tratamento totalmente diferente em situações iguais, com evidente violação ao princípio da isonomia.

Assim, v.g, aquela pessoa condenada à pena privativa de liberdade e que tenha sido presa provisoriamente terá abatido o período pelo próprio Juiz da Condenação para fins de progressão, podendo ser diretamente promovida de regime sem a observância do mérito; ao passo que o condenado, que não tenha cumprido prisão provisória, deverá obter a progressão com o preenchimento dos requisitos do artigo 112 da Lei das Execuções Penais a serem analisados pelo Juiz das Execuções Criminais. Há, portanto, dois pesos e duas medidas, ou seja, pessoas sendo tratadas de forma totalmente diferente em situações iguais, violando, assim, o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, "caput", da CF)"(<http://www.conjur.com.br/2012-dez-10/cesar-dario-lei-tornar-automatica-progressao-regime> - acesso em 17.12.2012, às 00h40min)

Ressalte-se: a modificação proposta pelo legislador é capaz de gerar odiosa injustiça, na medida em que os condenados que tenham sido submetidos a custódia cautelar durante o processo (justamente porque a sua liberdade colocava em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal – art. 312, do Código de Processo Penal) seriam beneficiados em detrimento daqueles que puderam responder ao processo em liberdade, provavelmente indivíduos menos perigosos para a sociedade.

E não é só. A antecipação da detração penal acarreta a supressão, no caso de réus presos cautelarmente, das regras para progressão de regime de cumprimento de pena privativa de liberdade, o que também se reflete em insustentável atentado ao princípio da isonomia.

Tudo isso sem considerar a possibilidade de que o réu esteja preso em razão de prisão preventiva decretada em vários processos, quando a aplicação irrestrita do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal poderá acarretar a consideração do mesmo período de prisão cautelar para fins de detração em várias sentenças condenatórias, o que não se pode admitir.

Assim, por entender que o art. 387, §2º, CPP viola a disciplina constitucional, deixo de aplicá-lo, o que faço com arrimo no controle de constitucionalidade difuso.

Douglas Henrique dos Santos de Paula:

Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, não observo motivos que ensejem a majoração da pena-base, ao que a mantenho no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Presente a agravante prevista no artigo 61, II, "j", CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo). No mais, reconheço a atenuante da menoridade relativa (fls. 168 – artigo 65, inciso I, do Código Penal) e mantenho a pena no patamar anterior.

Na terceira fase, afasto a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006, pelo motivo acima mencionado. Todavia, aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à mingua de suficiente comprovação de que o acusado se dedicasse a atividade criminosa por tempo considerável antes dos fatos ou integrasse organização criminosa. Assim, diminuo a reprimenda de 2/3, tornando-a definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

Considerando a primariedade do réu, fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado. O crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos, notadamente patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão dos benefícios mencionados, além de ser incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no artigo 44, III, CP.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para:

- 1) CONDENAR o réu RICHARD GABRIEL DOS SANTOS DE PAULA, qualificado nos autos, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, mas para ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, CPP;
- 2) CONDENAR o réu DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS DE PAULA, qualificado nos autos, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 166 dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, mas para ABSOLVÊ-LO da prática do crime previsto no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, CPP;
- 3) ABSOLVER as rés GABRIELA APARECIDA DA SILVA e ELIANA LUCIA DOS SANTOS, com fulcro no artigo 386, VII, CPP.

Nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06, declaro o perdimento dos objetos e celular apreendidos com os réus Douglas e Richard.

O acusado Richard não poderá recorrer em liberdade. Preso durante o curso do processo, com maior razão agora deverá permanecer custodiado. Recomende-se, pois, na prisão em que se encontra. Faculto o apelo em liberdade para Douglas, pois assim permaneceu no curso do processo.

Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Jaú, 02 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA